

1502150-62.2021.8.26.0544

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Renata Marques de Jesus

Comarca: Francisco Morato

Foro: Foro de Francisco Morato

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 09/02/2022

... Justiça: "DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. 1. O § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 dispõe que, para o crime de tráfico de entorpecentes e suas figuras equiparadas, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Francisco Morato

Foro de Francisco Morato

1ª Vara

Rua João Mendes Júnior, 626, Jardim Francisco Morato, Francisco Morato - SP - cep 07910-220

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1502150-62.2021.8.26.0544

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ISRAEL LEITE DA SILVA

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Data da Audiência:

09/02/2022

Réu Preso

Aos 09 de fevereiro de 2022, às 16 horas, nesta cidade de Francisco Morato, na sala de audiências do Juízo da Primeira Vara da Comarca de Francisco Morato, sob a presidência do(a) Meritíssimo(a) Juiz(a) de Direito Dra. Renata Marques de Jesus, comigo escrevente abaixo assinado. Presente representante do Ministério Público Dr. João Paulo Robortella, foi aberta audiência de instrução e interrogatório (na forma virtual, conforme o art. 17, da Resolução n.º 329/2020 do CNJ, e o item 13, do Comunicado CG 284/2020), nos autos da ação e entre as partes supra referidas. Aberta com as formalidades legais e apregoadas as partes, compareceram: o réu ISRAEL LEITE DA SILVA, acompanhado por advogado(a) nomeado(a) Dr.(a) Jucineide Gomes dos Santos de Moraes, que realizou reunião privada (item 8.1, do Comunicado CG 284/2020). Presente(s) a(s) testemunha(s) EDUARDO PARPINELLI JUNIOR e LEANDRO FERREIRA DE FARIA, a(s) qual(is) foi(ram) ouvida(s). Terminada a(s) inquirição(ões), foi colhido o interrogatório do(s) réu(s). O(s) depoimento(s) foi(ram) gravado(s) através do Microsoft Teams, arquivado(s) na plataforma One Drive e não será(ão) transcrito(s) em papel (Provimento 8/2011 da Egrégia Corregedoria da Justiça), permitindo aos procuradores o acesso a qualquer tempo, que constitui, nos termos do art. 405, § 1º e 2º do CPP, meio idôneo de documentação e se destina a obter maior fidelidade das informações. Pelo(a) MM.(a) Juiz(a) de Direito foi dito: Considerando que as partes não postularam novas diligências, declaro encerrada a instrução. Passo a palavra ao representante do Ministério Público para alegações finais, seguido pela Defesa. Pelo Ministério

Público foi dito: "MM. Juiz(a), ISRAEL LEITE DA SILVA foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas) c.c artigo 61, inciso II, alínea "j" (estado de calamidade pública), do Código Penal.O acusado foi notificado (fls. 123) e apresentou defesa prévia (fls. 131/132). A denúncia foi recebida em 14 de janeiro de 2022 (fls. 133/134). Em audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas nos autos, procedendo-se ao interrogatório do réu.Assim, vencida a fase instrutória, a pretensão punitiva deve ser julgada procedente.A materialidade do delito está comprovada por meio do auto de exibição e apreensão de fls. 12, laudo de constatação preliminar de fls. 14/17 e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 98/100.A autoria é inequívoca, comprovada pelo auto de prisão em flagrante e pela prova oral produzida.A testemunha Eduardo Parpinelli Junior, policial civil, relatou que, na data dos fatos, durante diligências em uma viela conhecida como ponto de venda de drogas, avistou o acusado com uma sacola em mãos. Realizada a abordagem, localizou na sacola cerca de 400 porções de drogas, entre maconha, cocaína e "k2". Havia uma escola próxima ao local da abordagem.No mesmo sentido foi o depoimento do policial civil Leandro Ferreira de Faria.Com efeito, as testemunhas corroboraram os fatos descritos na denúncia.Em seu interrogatório, o réu negou a prática do crime.Sua negativa, porém, desponta isolada nos autos e não se sustenta frente aos contundentes elementos de prova em seu desfavor.Ressalte-se que os policiais, na qualidade de agentes públicos, gozam de fé pública e não há nenhum elemento nos autos a abalar sua credibilidade. Pelo contrário: tais depoimentos se mostraram em consonância com o restante da prova produzida. Seus testemunhos, portanto, possuem pleno valor probatório, tanto que estão sujeitos a crime de falso testemunho como qualquer cidadão, conforme orientação da jurisprudência: TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DO ÉDITO REPRESSIVO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADA. 1. Para se desconstituir o édito repressivo, como pretendido no writ, seria necessário o exame aprofundado de provas, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus, mormente pelo fato de que vigora no processo penal brasileiro o princípio do livre convencimento, em que o julgador pode decidir pela condenação, desde que fundamentadamente. 2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido. (STJ, HC 236.105/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe 12/06/2014, os destaques não são do original); PENAL. PROCESSUAL PENAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SUFICIÊNCIA DA PROVA. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. TESTEMUNHO DE AGENTE POLICIAL COLHIDO NA FASE JUDICIAL. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. VALIDADE. PRECEDENTES. 1. Não há violação do art. 619 do Código de Processo Penal quando o Tribunal de a quo explicita, de forma clara e fundamentada, os elementos de sua convicção. Na hipótese, a Corte de origem enfrentou todas as omissões apontadas nos aclaratórios opostos pela defesa. 2. O exame da pretensão recursal no sentido da ausência de elementos probatórios suficientes para demonstrar a conduta de tráfico e associação para o tráfico, implica a necessidade de revolvimento do suporte fático-probatório delineado nos autos. Incidência da Súmula n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça. 3. É válido como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp 234.674/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/05/2014, DJe 06/06/2014, os destaques não são do original). Ademais, já asseverou o Desembargador José Renato Nalini: "é valioso o depoimento de policiais em hipóteses como a presente. O agente da segurança é recrutado mediante concurso público para atuar em prevenção e repressão à criminalidade e não é sensato negar-lhe crédito quando, perante o mesmo Estado que o contratou, relata atos de ofício. É compromissado como qualquer outra

testemunha e a circunstância de inexistir pessoa não pertencente aos quadros policiais para depor é justificável. Seria até perigoso envolver cidadãos que não são remunerados para reprimir a criminalidade em diligências potencialmente vulneradoras de irrecuperáveis bens da vida como a narrada nestes autos" (TJSP - Autos de Apelação nº 141.299-3/3 - Segunda Câmara - v.u.).O propósito da traficância é certo, haja vista: (1) a natureza, diversidade e a considerável quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas; (2) a forma de acondicionamento das substâncias em diversas porções individuais, prontas para entrega ao consumo de terceiros; (3) o local dos fatos, já conhecido como ponto de tráfico de drogas; (4) a quantia em dinheiro apreendida, a qual era produto da venda ilegal de drogas; (5) a confissão do acusado.A causa de aumento do artigo 40, III da Lei de Drogas foi demonstrada pelo mapa de fls. 91, indicando que a prática do delito se deu nas proximidades de estabelecimento de ensino (menos de 100 metros).Assim, comprovou-se de forma inequívoca a prática do delito em apreço, bem como a tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade dos fatos imputados ao acusado, impondo-se, desta feita, a sua condenação.Passa-se, então à análise da pena a ser aplicada.Na primeira fase de dosimetria da pena, atentando-se aos parâmetros do artigo 42 da Lei nº 11.343/06, deve a pena-base ser fixada acima do mínimo legal, ante a elevada quantidade e diversidade de drogas apreendidas (mais de 400 porções de entorpecentes, de 5 diferentes espécies), o que revela a exacerbada potencialidade lesiva da conduta. Não obstante, deve a pena-base ser elevada em razão do acusado estar comercializando pedras de crack, pois é notória a altíssima lesividade desta droga, que possui rápido efeito e grande potencial de vício, cuja traficância vem destruindo famílias e causando sérias consequências à sociedade. Na segunda fase de aplicação da pena, deve ser reconhecida a circunstância agravante da reincidência (fls. 48/51), bem como a circunstância agravante prevista no art. 61, II, alínea "j" do Código Penal, tendo em vista que o delito foi cometido durante o estado de calamidade pública, decorrente da atual pandemia de COVID-19. Na terceira fase, ausentes os requisitos do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 em razão da reincidência do réu, incabível a aplicação do redutor. Incide, ainda, a causa de aumento de pena acima exposta. O regime inicial de cumprimento de pena deverá ser o fechado, a rigor do que dispõe o artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90 (Lei de Crimes Hediondos). Vedada a conversão em pena restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 da Lei nº 11.343/06, valendo destacar que se trata de delito equiparado a hediondo, a demandar maior rigor em sua reprimenda.Ante o exposto, o Ministério Público requer seja julgada procedente a pretensão punitiva, com a consequente condenação de ISRAEL LEITE DA SILVA, nos exatos termos da denúncia.Com o trânsito em julgado, requer-se o perdimento do dinheiro apreendido em favor da União, emitindo-se a respectiva guia, nos termos do artigo 63 da Lei 11.343/06". Pela Defesa foi dito: "MM. Juiz(a), em que pese todas as ponderações lançadas pelo i. Representante do Ministério Público, entretanto, imperioso salientar de que algumas ponderações deverão ser lançadas em favor do réu, visto que, conforme ficou devidamente comprovado nos autos, em nenhum momento manifestou qualquer tipo de resistência,

sendo que a todo momento, desde a apreensão do réu e das mercadorias com ele existente, o que comprova a materialidade dos fatos.Diante o exposto,Requer a concessão da liberdade provisória cumulada com as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, uma vez que a prisão é a ultima ratio a ser seguida pelo julgador, com imediata expedição de alvará de soltura;Em caso de entendimento diverso, com a condenação do acusado, que sejam consideradas favoráveis todas as circunstâncias judiciais da primeira fase da dosimetria (art. 59 CP), devendo a pena ser fixada no mínimo legal;Aplicação do regime inicial de cumprimento no aberto, nos termos do art. 33, § 3º, do CP;A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme o artigo 44, do CP;Seja concedido o direito do acusado recorrer em liberdade, já que caso condenado será fixado regime diverso do qual o acusado está sendo submetido,A gratuidade de justiça, com isenção de dias-multa e custas processuais, por se tratar de hipossuficiente nos termos da lei". Em seguida foi proferida a sentença pelo(a) MM.(a) Juiz(a) de Direito: "

Vistos. ISRAEL LEITE DA SILVA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", c.c. art. 40, III, ambos da lei nº 11.343/06, cc artigo 61, II, "j", do Código Penal, porque no dia 08 de setembro de 2021, por volta das 13h10, na Avenida São Paulo, altura do número 629, nesta cidade e Comarca de Francisco Morato, trazia consigo, para fins de tráfico, nas imediações de estabelecimento de ensino, 43 (quarenta e três) porções de "maconha" (cannabis sativa L.), com peso líquido aproximado de 58g (cinquenta e oito gramas); 149 (cento e quarenta e nove) porções de "cocaína", com peso líquido aproximado de 49,9g (quarenta e nove gramas e nove decigramas); 126 (cento e vinte e seis) porções de "crack", com peso líquido aproximado de 16,1g (dezesesseis gramas e uma decigrama), 27 (vinte e sete) porções de "skunk", com peso líquido de 9,2 (nove gramas e duas decigramas); e 82 (oitenta e duas) porções de "k2", com peso líquido de 40,2g (quarenta gramas e duas decigramas), substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (fls. 1/3). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls. 66/70). Notificado (fls. 122/123), o réu apresentou defesa prévia (fls. 131/132) e a denúncia foi recebida (fls. 133/134). Citação às fls. 153/154. Durante a instrução processual foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes e o réu interrogado. Mídia arquivada. Em debates o Ministério Público pugnou pela procedência do pedido, observando a impossibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, com início de cumprimento de pena no regime fechado. A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição ou, alternativamente, a fixação de pena mínima. É o relatório. Fundamento e decido. À luz das provas carreadas aos autos, a pretensão inicial merece prosperar em parte. A materialidade restou comprovada ante o auto de prisão em flagrante (fls. 4/7), boletim de ocorrência (fls. 9/11), auto de exibição e apreensão (fls. 12), laudos de constatação provisória (fls. 14/17), além dos exames químico-toxicológicos de fls. 98/100, que constatarem as presenças de tetrahydrocannabinol (THC) e de cocaína nas amostras analisadas. A autoria também é certa. Durante a fase extrajudicial o réu permaneceu em silêncio (fls. 7). Em juízo, por seu turno, disse que no dia que os policiais chegaram estava passando e só parou para falar com "os meninos". Já tinha comprado umas buchas. Os "meninos" correram e deixaram a bolsa com droga no local. Continuou seguindo, mas foi abordado. Tinha cerca de R\$ 100,00 e recebeu do trabalho de "marretar no trem". Estava indo levar lavagem para os porcos. Não conhece as testemunhas, trabalhava marretando no trem, com renda de R\$ 100 a 200,00 por dia, tem dois filhos menores de idade e já teve condenação por roubo, não sabendo dizer se já "assinou tudo". Esclareceu que estava andando quando foi abordado pelos policiais. Não tem escola próxima. Eduardo Parpinelli Júnior, policial civil que participou da ocorrência, afirmou que no local já foram feitas prisões em flagrante. É uma viela e dá um acesso precário à linha férrea. Os traficantes comumente se colocam no muro da linha. Passando-se pro transeunte foram ao local e se depararam com o réu. Com ele foi encontrada cerca de 400 porções de drogas, inclusive K2, com THC mais forte, e uma quantidade de dinheiro trocado. Não conhecia antes dos fatos. No momento o réu disse ter adquirido em São Paulo para venda. Tem um estabelecimento de ensino, sem saber precisar. O acusado estava sozinho. O trilho é usado por transeuntes, mas com ele não tinha ninguém. O entorpecente estava em uma sacola na mão do Israel. A corroborar, o também policial civil Leandro Ferreira de Faria declarou que o local é conhecido como ponto de venda de drogas e tentando minimizar os danos a sociedade foram ao local. O local dá acesso à linha férrea. Tem um buraco no muro e ali ocorrência a mercancia de entorpecentes. Passou-se por transeunte, junto com seu parceiro. O réu estava parado com uma sacola. Em abordagem com ele tinha cocaína, crack e maconha, além de dinheiro. Não o conhecia antes e ele assumiu a mercancia. Era em torno de 350 a 400 porções pronta para comercio e pouco mais de R\$ 100 trocados. Não se recordou de estabelecimento de ensino nas proximidades. Não viu ato de venda. Não houve campana. No momento da abordagem o réu estava parado com a sacola na mão. Fazem a abordagem só de pessoa parada sem um propósito aparente. É importante salientar que a lei penal não furta valor ao testemunho dos agentes de segurança, na medida em que não os dispensa do compromisso de dizer a verdade e nem

os poupa do crime de falso testemunho, caso venham a sonegar ou adulterar os fatos. Há de se levar em conta que o acusado e os policiais civis não se conheciam até então, de forma que estes não tinham motivos para acusá-lo leviana e gratuitamente. Ademais, a lei penal não furta valor ao testemunho dos agentes de segurança, na medida em que não os dispensa do compromisso de dizer a verdade e nem os poupa do crime de falso testemunho caso venham a sonegar ou adulterar os fatos. Aliás, nem teria sentido conferir-lhes a lei determinada tarefa para depois, quando viessem prestar contas de sua atuação, negar-lhes valor aprioristicamente, por preconceituosa admissão de que não dizem a verdade: "É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta Corte" (STJ, Sexta Turma, AgRg no Ag 1158921/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, julg. 17/05/2011, DJe 01/06/2011); "O depoimento de policial obedece os mesmos princípios aplicados ao restante das pessoas, não havendo que se falar em suspeição ou inidoneidade considerando-se somente a sua condição funcional" (TJSP, RT 752/586); "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo sob garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam, com outros elementos probatórios idôneos" (STF, HC nº 74.608-0, Rel. Min. Celso de Mello, j. 18/02/97, DOU de 11/04/97, p. 189); "Não se pode presumir em policiais ouvidos como testemunhas a intenção de incriminar falsamente o acusado da prática de crime contra a saúde pública na modalidade de tráfico de entorpecente por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário é de idoneidade destas testemunhas, ainda mais quando os seus depoimentos são seguros precisos e uniformes desde a sede inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição" (TJSP, RT 614/275); "Os policiais não são proibidos de prestar depoimento nos processos de cuja fase policial tenham participado, seja efetuando a prisão do agente, seja apreendendo o objeto do crime. De outro lado, a declaração de inidoneidade é específica e não genérica, não podendo abranger toda uma categoria de pessoas, devendo ser alegada e demonstrada em cada caso" (TJMG, RT 604/407). A partir do contexto probatório extrai-se que as testemunhas prestaram depoimentos coesos e convergentes, reafirmando as declarações prestadas na fase policial, tornando seguro um decreto condenatório. E, não demonstrou a Defesa eventual motivo que os policiais civis teriam para mentir em juízo deixando, assim de se desincumbir de seu ônus (artigo 156, do Código de Processo Penal), destacando que eventuais e pequenas contradições entre os depoimentos, sequer existentes na hipótese, não são capazes de infirmar a lisura do trabalho policial. Nesse sentido: "PROVA - Pequenas divergências entre os relatos das testemunhas - Irrelevância - Validade. As pequenas contradições na prova decorrem das próprias imperfeições do psiquismo humano, agravadas, em geral, pelas condições em que a prova é realizada. Assim, de se desconfiar do testemunho demasiado perfeito, sendo, sim, importante, verificar se, embora discrepantes em detalhes mínimos, concordam os depoimentos nos pontos essenciais, quanto às circunstâncias decisivas do fato" (TACrimSP - Ap. nº 583.153/2 - 7ª Câmara - Rel. José Habice - J. 05.04.90 - RJDTACRIM 6/78). Tenta-se, em vão, diminuir o valor dos depoimentos dos policiais, o que não se sustenta diante do quadro probatório existente e dos elementos de convicção formados. Nesse ponto, é preciso ficar claro que a inexistência de testemunhas civis e 'eventuais compradores' no ato da prisão em flagrante não o invalida, cumprindo ressaltar que em delitos da espécie, como cediço, ainda que populares presenciem a atividade criminosa, estes não querem se identificar com medo de represálias por parte dos criminosos. Dentro desse quadro, os depoimentos das testemunhas comuns ouvidas sob o crivo do contraditório, repita-se, foram harmônicos e convergentes, levando à certeza da autoria. Sendo assim, a

variedade, a quantidade e a nocividade das drogas apreendidas, a forma como embaladas, o fato de o local da apreensão ser conhecido dos meios policiais como ponto de venda de entorpecentes, bem como o depoimento seguro prestado pelas testemunhas, levam à certeza de que o réu traficava drogas na ocasião, impondo-se a condenação. Destaca-se que o crime de tráfico de entorpecente

é de mera conduta, bastando, para a sua consumação, a prática de qualquer um dos núcleos verbais do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, independentemente da concretização ou não da entrega ao destinatário, pelo que as simples condutas do réu, consistentes em “trazer consigo” as substâncias entorpecentes, já são suficientes para caracterização do delito: “Nunca é demais lembrar, de outro lado, que é desnecessária a prova de ato de comércio, bastando que o agente traga consigo ou mantenha em depósito a droga para esta destinação, ainda que futura, na medida em que a consumação não exige resultado” (TJSP – Apel. Crim. nº 990.09.088010-4 – 5ª Câmara Criminal – Campinas – v.u. – j. 03.09.09 – Rel. Des. Pinheiro Franco). No mesmo sentido: “O crime de tráfico de entorpecentes é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a simples possibilidade de distribuição (gratuita ou onerosa) do entorpecente” (RT 776/663); “Não é indispensável à prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido” (RT 729/542); “Cabe ressaltar que para a caracterização do crime de tráfico de entorpecentes não é necessária a prova flagrante do comércio ilícito, sendo suficientes os elementos indiciais apurados no caso concreto, bem como as circunstâncias da prisão para evidenciar tal atividade ilícita”. (TJ/SP – Apel. Crim. nº 990.09.235417-5 – 14ª Câmara Criminal – v.u. – j. 11.03.10 – Rel. Des. Fernando Torres Garcia). Ressalta-se que a considerável quantidade e variedade de entorpecente, além da forma como se deu sua apreensão demonstram a traficância e não autorizam eventual classificação da conduta como simples consumo pessoal (artigo 28, da Lei nº 11.343/06): “DESCCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO DE USO - Inadmissibilidade - Quantidade e diversidade de entorpecentes - Conjunto probatório suficiente para ensejar o decreto condenatório - Inexistência de prova segura que autorizasse decretar nova definição jurídica da conduta.” (TJSP, 16ª Câmara de Direito Criminal, Apelação nº 990.08.080898-2, Des. Rel. Leonel Costa, j. 28/04/09). E o fato de o acusado eventualmente afirmar que é usuário de droga, não é suficiente para a desclassificação do delito de tráfico, sendo, repita-se à exaustão, a condenação de rigor. Vale destacar, ainda, que a condição de usuário não é incompatível com a de traficante: “(...) a mera condição de usuário ou dependente, por si só, não possui o condão de excluir a culpabilidade pelo narcotráfico, porquanto, em muitos dos casos, os usuários se valem dessa mercancia ilícita para provar o sustento do próprio vício, de tal forma, que uma conduta nem sempre pode excluir a outra.” (TJSP, AC nº 0000318-44.2016.8.26.0544, Rel. Des. França Carvalho, j. 05/04/2018). “A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente há hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade” (TJSP RJTJSP 101/498); “Importante consignar que o fato de o acusado ter declarado que era usuário de drogas não afasta sua condição de traficante, uma vez que os usuários, frequentemente, também passam a comercializar entorpecentes, justamente para obter dinheiro e garantir o vício e o próprio sustento, acrescentando-se, por oportuno, que uma conduta não exclui a outra” (TJSP; 9ª Câmara Criminal, Ap. n.º 0001866-59.2015.8.26.0635, Rel. Sérgio Coelho, j. em 31.03.2016); “Nenhuma incompatibilidade existe entre o tráfico de entorpecente e o vício. Ao contrário. Em regra, vivem associados” (RT 411/104). Cabe observar, nesse passo, que a apreensão de não desprezível quantidade de substância entorpecente em poder do agente, além da circunstância de estar separada em unidades diferentes ou dividida em porções, conduz à segura conclusão de que se destina ao comércio ilícito, e não ao uso próprio. Por fim, não restou efetivamente comprovada a presença da causa de aumento constante no art. 40, III, da lei nº 11.343/06. As testemunhas atestaram a

existência de escola sem, contudo, precisar distância. E o documento de fls. 91 não é suficientemente claro em apontar a distância do local da abordagem até o referido estabelecimento de ensino. Assim, as provas constantes dos autos não revelam que o réu se encontrava, de fato, nas "imediações" desse local, mostrando-se insuficientes para configurar a presença da agravante: "TRÁFICO DE DROGAS - DESCLASSIFICAÇÃO NA ORIGEM PARA POSSE PARA USO - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PRETENDIDA A condenação do acusado PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - acolhimento - PROVAS SUFICIENTES EM RELAÇÃO À FINALIDADE MERCANTIL DA CONDUTA - Materialidade e autoria delitiva comprovadas - réu detido em posse DE 05 PORÇÕES DE MACONHA, SOB CIRCUNSTÂNCIAS INDICATIVAS DA TRAFICÂNCIA - PALAVRA DOS POLICIAIS - VALIDADE - LOCAL CONHECIDO COMO PONTO DE VENDA E ACUSADO SABIDAMENTE VINCULADO À TRAFICÂNCIA - dosimetria - CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, III, DA LEI Nº 11.343/06 NÃO COMPROVADA - DISTÂNCIA DE MAIS DE 500 METROS EM RELAÇÃO A ESTABELECIMENTO DE ENSINO e 350 metros em relação a campo de futebol - EM RAZÃO DA COMPROVADA DEDICAÇÃO HABITUAL AO TRÁFICO E ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS, O RÉU NÃO FAZ JUS AO BENEFÍCIO DA Redução, PREVISTA NO § 4º, do ART. 33, da lei nº 11.343/06 - regime inicial fechado se mostra imperioso - recurso parcialmente provido." (TJSP; 9ª Câmara de Direito Criminal; Apelação 0000242-78.2016.8.26.0557; Relator: Amaro Thomé; Data do Julgamento: 09/11/2017; Data de Registro: 16/11/2017); "(...) A interpretação literal e teleológica do referido inciso III, que alude a "dependências" e "imediações" dos locais ali discriminados, revela que o dispositivo busca reprimir com mais intensidade a conduta de quem pratica o tráfico no próprio local em suas instalações ou nas adjacências, isto é, nas cercanias, circunstância que reclama efetiva proximidade, pouca distância, propiciando que o agente tire proveito do fluxo ou circulação das pessoas que frequentam ou visitam aqueles lugares, desautorizando, portanto, a incidência da majorante a hipóteses como a dos autos (...)" (TJSP; 11ª Câmara de Direito Criminal; Apelação 1500139-51.2020.8.26.0623; Relator: Otavio de Almeida Toledo; Data do Julgamento: 11/12/2020). Destarte, comprovadas a autoria e a materialidade, inexistindo causa de exclusão da ilicitude, a ação penal é procedente, amoldando-se a conduta praticada pelo réu à figura típica prevista no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06. Passo a dosar a pena: Sopesados os elementos norteadores do art. 59, do Código Penal e em observância ao disposto no artigo 42, da Lei nº 11.343/06, que autoriza que o magistrado considere na primeira fase de dosimetria a natureza do entorpecente, a quantidade, a personalidade e a conduta social do agente, de rigor a fixação da pena-base acima do mínimo legal (v.g. STF, HC nº 96.655, rel. Min. Cármen Lucia; STF, HC nº 107.784, rel. Min. Ricardo Lewandowski; STJ, HC nº 237.837, rel. Min. Laurita Vaz; STJ, HC nº 235.524, rel. Min. Jorge Mussi; STJ, HC nº 223.447, rel. Min. Laurita Vaz; STJ, HC nº 179.086, rel. Min. Gilson Dipp). No mesmo sentido: "REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ELEVADA QUANTIDADE DO ENTORPECENTE APREENDIDO. POSSIBILIDADE. AUMENTO PROPORCIONAL. 1. Na fixação da pena-base de crimes previstos na Lei n. 11.343/2006, como ocorre na espécie, deve-se considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei de Drogas. 2. Na espécie, a reprimenda de piso acima do mínimo legal, em razão da natureza e a excessiva quantidade do estupefaciente apreendido, encontra-se devidamente justificada e proporcional às especificidades do caso versado. [...] 2. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no AREsp 585.375/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 16/3/2017, DJe 27/3/2017); O réu é reincidente (fls. 48/51), o que será oportunamente apreciado, e foi encontrado com entorpecente sintético conhecido por "K2", de elevado poder destrutivo, com "crack" e cocaína, substâncias de alto poder viciante, que causam dependência física e psíquica, mesmo que utilizados apenas uma única vez, motivo que enseja uma maior reprimenda, pois seria desarrazoado punir aquele que vende "maconha" na mesma medida daquele que vende entorpecente altamente viciante, que além de causar um impacto muito maior na saúde do usuário, ainda repercute na sociedade e na família, somado ao fato de corroborar com a prática delitiva daqueles que não possuem condições financeiras de sustentar

o vício. Segundo o entendimento de Guilherme de Souza Nucci, "A Lei de Drogas baseia-se, principalmente, na punição de crimes de perigo abstrato, o que justifica destacar, como elementos preponderantes na individualização da pena, dentre outros, a natureza e quantidade da substância ou do produto. É natural supor que, quanto maior for a quantidade de drogas ilícitas em circulação, maior será o perigo em relação à saúde pública. Ademais, quanto mais forte for a droga ilícita, igualmente, mais grave será a consequência em virtude de sua utilização. Estes fatores, portanto, podem e devem ser levados em conta pelo magistrado" (in Leis penais e processuais penais comentadas, 4ª edição, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 378). No mesmo sentido, defende Ricardo Brasileiro de Lima que "Como se trata de crime contra a saúde pública, quanto mais nociva a substância ou quanto maior a quantidade de droga apreendida, maior será o juízo de censura a recair sobre a conduta delituosa. De fato, não se pode equiparar a conduta daquele que é preso com um quilograma de maconha com a daquele que é preso com um quilograma de cocaína, já que esta droga tem um caráter viciante e destrutivo bem mais elevado que aquela" (in Legislação criminal especial comentada, 2ª edição, JusPODIVM, 2014, p. 787). Registre-se que a cocaína é considerada um dos entorpecentes mais nefastos e viciantes, o que traz maiores danos à saúde pública, sendo de rigor a fixação da pena-base acima do mínimo legal, por ser proporcional à quantidade e natureza. Frisa-se que as substâncias conhecidas como "skank" e "K2" são consideradas muito potentes e trazem maiores danos à saúde pública, sendo de rigor a fixação da pena-base acima do mínimo legal, por ser proporcional à quantidade e natureza. Assim, ponderando tal circunstância (natureza), fixo a pena-base com o acréscimo de 1/6 (um sexto), ou seja, em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Quanto à fração a ser aumentada, vale destacar não haver previsão legal valorando o quantum, ficando a critério do magistrado analisando o caso concreto: "o magistrado fixa a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (STJ, AgRg no REsp nº 143.071/AM, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 6/5/2015). Prosseguindo, nos termos do artigo 68, do Código Penal, dever ser reconhecida a reincidência (autos nº 0088586-77.2011.8.26.0050 - fls. 48/49). Também deve ser reconhecida a agravante prevista no art. 61, II, alínea "j", do Código Penal, na medida em que o crime foi cometido durante o período da pandemia causada pelo novo coronavírus (COVID-19), quando já estava decretado o estado de calamidade pública, com recomendação do isolamento social e outras medidas públicas (Decreto Estadual nº 64.879/20 e Decreto Legislativo nº 6/2020), o que reduz a vigilância. A prática de crime em cenário no qual toda a população passa por privações e incertezas e em meio a diversas recomendações de recolhimento domiciliar e restrição de atividades de toda ordem é ainda mais reprovável e merece resposta penal diferenciada. A situação atualmente vivida é excepcional e, sem dúvida, do conhecimento de todos, motivo pelo qual aumento a pena em 1/3 (um terço), estabelecendo-a em 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 777 dias-multa dias-multa: "TRÁFICO DE ENTORPECENTES PRIVILEGIADO. APELO MINISTERIAL. PLEITOS DE RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, "J", DO CÓDIGO PENAL, E DE AFASTAMENTO DO PRIVILÉGIO, COM READEQUAÇÃO DAS PENAS. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. Base fixada em 1/6 acima do mínimo legal, valoradas como negativas as circunstâncias relacionadas à natureza da droga (cocaína, acondicionada na forma de tijolos) e do seu transporte entre cidades. Na segunda etapa, pedido ministerial acolhido, para reconhecimento da agravante da prática de crime em ocasião de calamidade pública (art. 61, II, "j", do CP). Prática do crime durante a pandemia de COVID-19. Lei não prevê nenhuma condicionante finalística ou modal para que a agravante incida. Mantido o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, as penas ainda foram reduzidas em 1/10, dada a preponderância da atenuante (art. 67, CP). A quantidade dos entorpecentes apreendidos (quase dois quilogramas de cocaína) e seu alto valor no comércio clandestino de entorpecentes demonstram envolvimento do apelado em atividades criminosas, impedindo, portanto, a incidência do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, o qual fica afastado. Penas redimensionadas para 5 anos e 3 meses de reclusão e 524 dias-multa. REGIME



PRISIONAL. Imposição do regime inicial fechado, ante a pena concretizada e as circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 33, parágrafo 3º, do Código Penal), a par da gravidade concreta do delito praticado. BENEFÍCIOS LEGAIS. Incabível a concessão de sursis ou de substituição da pena corporal por restritivas de direitos, ante a quantidade de pena concretizada, Recurso ministerial provido para, afastado o privilégio e reconhecida a agravante do art. 61, II, "j", do CP, redimensionar as penas do apelado, bem como fixar-lhe o regime inicial fechado." (TJSP; Apelação Criminal 1522780-54.2020.8.26.0228; Relator (a): Gilda Alves Barbosa Diodatti; 15ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 28/04/2021; Data de Registro: 28/04/2021) – grifos nossos. Na terceira fase não é o caso de incidência da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, ou seja, do reconhecimento do crime de "tráfico privilegiado". Restou demonstrado que o réu trazia consigo elevada quantidade de entorpecentes (mais de 425 gramas de drogas – fls. 12) e variedade, inclusive com substância sintética de alto poder destrutivo, a indicar um acentuado envolvimento no comércio de drogas, ou seja, a não ocasionalidade da conduta. Além disso, não demonstrou o exercício de atividade lícita, além de ser reincidente. Quadro, pois, a desnudar que se trata de pessoa dedicada às atividades criminosas. Enfim, havendo indícios do envolvimento do acusado com a criminalidade, descabido o redutor previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, valendo trazer à colação, como já se decidiu, que a conduta social do réu, a quantidade e a natureza do entorpecente, além das circunstâncias em que a droga foi apreendida podem constituir o amparo probatório para o magistrado reconhecer a dedicação do réu à atividade criminosa (RHC nº 116.926/DF, rel. Min. Luiz Fux, j. em 20.8.2013; HC nº 116.541/ES, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 6.6.2013; HC nº 98.366/MG, rel. Min. Dias Toffoli, DJe 5.2.2010). Nesse sentido o C. Superior Tribunal de Justiça: "DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. 1. O § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 dispõe que, para o crime de tráfico de entorpecentes e suas figuras equiparadas, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa. 2. No caso em análise, com base na grande quantidade de drogas apreendidas, as instâncias ordinárias concluíram que o paciente dedica-se à atividade criminosa. 3. "Tanto o Supremo Tribunal Federal quanto esta Corte Superior de Justiça firmaram o entendimento de que a apreensão de grande quantidade de drogas, a depender das peculiaridades do caso concreto, é hábil a denotar a dedicação do acusado a atividades criminosas ou mesmo a sua integração em organização criminosa" (HC 373.523/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe de 21/08/2018). 4. Embora a quantidade de entorpecentes apreendidos já tenha sido utilizada na primeira fase da dosimetria penal, para exasperar a pena-base, nada impede que tal circunstância seja novamente considerada na terceira etapa, para aferir a traficância habitual e, consequentemente, obstar o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006." (AgRg no HC 499936 Rel. Min. Jorge Mussi julg. 25/06/2019 publ. 01/07/2019). "PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE AUMENTO DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE. AGENTE QUE INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HISTÓRICO CRIMINAL. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. APLICAÇÃO DA NORMATIVIDADE REGENTE. QUANTUM DE PENA A IMPEDIR A SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (...) VI - In casu, há fundamentação concreta para o afastamento do tráfico privilegiado, consubstanciada na grande quantidade e na natureza da droga apreendida, ou seja, "670 g de maconha". Assim, a Corte originária se convenceu de que o paciente se dedicava, efetivamente, às atividades criminosas, porque não se tratava de traficante ocasional" (Quinta Turma, AgRg no HC 548913/MS. Relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo. Julgado em 10/03/2020. DJe 18/03/2020). Esta pena torna-se definitiva, tendo em vista a inexistência de outras causas de aumento e de diminuição. O valor do dia-multa deve ser calculado nos termos do artigo 43, da Lei nº 11.343/06, sendo fixado em um trinta avos do

salário mínimo vigente à época do pagamento, tendo em vista a situação econômica do acusado. O tráfico de entorpecentes é crime gravíssimo, pois pressupõe violência e grave ameaça à sociedade, principalmente por atingir a sua população mais jovem e vulnerável, aumentando os índices de criminalidade, desestruturando cada vez mais famílias e trazendo danos de toda sorte aos envolvidos, tendo o traficante a intenção de levar ao vício o maior número possível de vítimas. Além disso, não se pode olvidar a natureza da infração e os males que ela provoca no seio social, devendo o infrator experimentar repercussões objetivas acerca da censurabilidade de sua conduta, razão pela qual o réu deverá cumprir sua pena em regime inicialmente fechado: "TRÁFICO DE DROGAS PEDIDO SUBSIDIÁRIO - FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO INADMISSIBILIDADE - REGIME INICIAL FECHADO ADEQUAÇÃO À ESPÉCIE DELITO EQUIPARADO A HEDIONDO - INTELIGÊNCIA DA LEI Nº 11.464/2007. Ressalto que há determinação expressa no artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, de que as penas por crime hediondo ou equiparado iniciam-se no regime fechado. RECURSO NÃO PROVIDO." (TJSP; 6ª Câmara de Direito Criminal; AP 0057527-71.2011.8.26.0050; Relator Marco Antonio Marques da Silva, data do julgamento: 27/06/2013).

Vale lembrar que embora o Supremo Tribunal Federal tenha declarado a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei 8.072/90 (HC 111.840/ES), a r. decisão não foi unânime e foi feita de forma incidental, não possuindo eficácia erga omnes e nem efeito vinculante. E, não sendo o caso de reconhecimento da causa de diminuição prevista no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, conforme justificado, não há que se falar em aplicação da determinação proferida no Habeas Corpus Coletivo nº 596.603/SP, do C. Superior Tribunal de Justiça (Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz), que determinou a fixação do regime aberto em relação aos presos que "se encontrem na mesma situação (condenados, por delito de tráfico privilegiado, a 1 ano e 8 meses, em regime fechado)", estabelecendo, dentre outras determinações, que "aos condenados que atualmente cumprem pena por crime de tráfico privilegiado, em que se reconhecem todas as circunstâncias como favoráveis, e aos que vierem a ser sancionados por tal ilicitude (mesmas circunstâncias fáticas), determinar que não se imponha - devendo haver pronta correção aos já sentenciados - o regime inicial fechado de cumprimento da pena" (grifo nosso). As condições pessoais do réu não são idênticas às daqueles para os quais se determinou a concessão de regime inicial aberto, merecendo destaque a presença da agravante da reincidência. Ainda que assim não fosse, impossível a conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos ou a suspensão condicional da pena, diante do montante da pena, da reincidência e também da gravidade concreta do delito, tendo em vista a quantidade, natureza e diversidade das drogas apreendidas, somando um total líquido aproximado de 425g, o que justifica a não substituição da reprimenda (STJ, Quinta Turma, HC 24914/SP, Rel. Min. Marilza Maynard, j. 14/04/2013) : "TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - 11,2G DE COCAÍNA, 179,1G DE MACONHA E 554ML DE LANÇA-PERFUME - PENAS - AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, "j" - IMPOSSIBILIDADE - O NECESSÁRIO ISOLAMENTO SOCIAL DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS GARANTIU, POR INFELIZ VIA TRANSVERSA, O ANONIMATO E A IMPUNIDADE DE USUÁRIOS E TRAFICANTES - AGRAVANTE MANTIDA APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06 - IMPOSSIBILIDADE - VULTOSA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA A INDICAR QUE O ACUSADO, CONQUANTO PRIMÁRIO, FAZ DO TRÁFICO SEU MEIO DE VIDA - REGIME FECHADO ADEQUADO - EVENTUAL ABRANDAMENTO NÃO SERIA SUFICIENTE PARA ATENDER AO ASPECTO QUALITATIVO DA PENA - IMPROVIMENTO DO RECURSO" (TJSP; Apelação Criminal 1514354-53.2020.8.26.0228; Relator (a): Willian Campos; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 19/10/2020; Data de Registro: 19/10/2020) - grifos nossos. Ademais, tais benefícios são incompatíveis com a finalidade da Lei nº 8.072/90, que dá tratamento mais rigoroso aos chamados crimes hediondos e assemelhados e que prevê, dentre outras hipóteses, a fixação de regime inicial fechado para cumprimento da sanção imposta ao protagonista de delitos deste jaez. Pelo mesmo motivo e diante da persistência dos requisitos que mantiveram a prisão cautelar durante o curso do processo, o acusado não poderá recorrer em liberdade. Assim, deverá manter-se recolhido para poder recorrer, até porque seria um contrassenso libertá-lo após a sentença que o condenou. Expeça-se mandado de prisão, recomendando-se na prisão em que se

encontra, bem como guia de recolhimento provisória, encaminhando-a, com as peças obrigatórias, ao Juízo da Execução competente. Ante o exposto e tudo mais que dos autos consta JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido para condenar ISRAEL LEITE DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da lei nº 11.343/06, c.c. artigo 61, II, "j", do Código Penal, fixando-lhe a pena privativa de liberdade de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 777 dias-multa dias-multa, fixados no valor mínimo legal. Em observância ao disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, verifico que o réu encontra-se preso preventivamente a cinco meses, contudo, não há elementos nos autos - principalmente os subjetivos - para eventual colocação em regime mais benéfico, que fica condicionada à demonstração de que ostenta bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento prisional, bem como à verificação de que não se encontra preso, provisória ou definitivamente em razão de outro processo. Eventual progressão, portanto, quando cabível, deverá ser verificada em sede do Juízo das Execuções Criminais, a ele competindo proceder às adequações necessárias em caso de existência de outras condenações penais, nos termos dos artigos 66, III, "a" e 111, ambos da Lei nº 7.210/84: "Finalmente, é inviável em sede de apelação a aplicação do disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, devendo o juízo da execução se manifestar inicialmente a respeito de eventual detração, primeiramente porque não se tem informações, aptas a embasar decisão segura, a respeito da real situação carcerária do recorrente, e principalmente para não violar o princípio constitucional do duplo grau de jurisdição, não convencendo a tese defensiva de revogação tácita da competência do juiz da execução para conhecer da matéria." (TJSP - 5ª Câmara Criminal - Apelação Criminal nº. 3002467-98.2013.8.26.0565 - Rel. Des. Tristão Ribeiro - j. 02.07.2015, v.u.). Recomende-se o réu na prisão em que se encontra. Com efeito, como acima fundamentado, respondeu ao processo preso, sendo certo que persistem e nesta sentença são reforçados os requisitos e pressupostos da prisão cautelar. Autorizo a incineração das drogas, nos termos dos artigos 50, §§ 3º e 4º e 72, ambos da Lei de Tráfico, destruindo-se amostras guardadas para contraprova. Comunique-se nos termos dos art. 524-A, § 2º, e 525, das NSCGJ, caso tal providência ainda não tenha sido adotada. Nos termos dos artigos 63, I e § 1º, e 64, ambos da Lei nº 11.343/06, decreto o perdimento da quantia apreendida em poder do acusado (fls. 12), pois decorrente da prática do crime em questão. Oficie-se, observando o depósito às fls. 95/96. Na forma do artigo 804 do Código de Processo Penal e do artigo 4º, § 9º, alínea "a", da Lei nº 11.608/03, condenado, o réu arcará com as custas processuais: "o réu, ainda que beneficiário da assistência judiciária gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, ficando, contudo, seu pagamento sobrestado, enquanto perdurar seu estado de pobreza, pelo prazo de cinco anos, quando então a obrigação estará prescrita, conforme determina o art. 12 da Lei 1.060/50. Precedentes. A isenção somente poderá ser concedida ao réu na fase da execução do julgado, porquanto esta é a fase adequada para aferir a real situação financeira do condenado, já que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação" (REsp. 400.682, Rel. Min. Laurita Vaz, DJ 17/11/ 2003,). No mesmo sentido: REsp. 262.961, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJ 17.06/2002; REsp. 263.021, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 18.03/2002 e REsp. 81.304, Rel. Min. Edson Vidigal, DJ 14/09/98. Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso." - grifos nossos (TJSP, 4ª Câmara de Direito Criminal, Apelação nº 0008903-30.2009.8.26.0189, Relator Des. Euvaldo Chaib) Expeça-se certidão de honorários à advogada nomeada nos autos (fls. 124), nos termos da tabela DPE/OAB vigente. Após o trânsito em julgado oficie-se ao TRE, para fins do disposto no artigo 15, III da Constituição Federal; expeça-se guia de execução definitiva e arquivem-se os autos, com as anotações necessárias." Pelo Ministério Público foi dito não ter interesse em recorrer. Assim, certifique-se de imediato o trânsito em julgado para a acusação. A Defesa manifestou interesse em recorrer da sentença. Assim, recebo o Recurso interposto, devendo a i. Defesa apresentar as razões no prazo legal. Após, ao Ministério Público para contrarrazões". Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Nada mais. Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Eu, Geziel Gomes Barbosa,

Escrevente Téc. Judiciário, subscrevi.

MM. Juiz(a) de Direito:

Promotor de Justiça:

Réu:

Defesa:

Certifico e dou fé que o presente termo foi lido e achado conforme pelas partes presentes e por seus procuradores, os quais saem intimados de seu inteiro termo nada tendo a opor quanto ao seu conteúdo. Certifico ainda que, havendo sido presente o termo assinado eletronicamente pelo(a) MM.(a). Juiz(a) que à mesma presidiu, dispensa-se a assinatura das partes presentes. NADA MAIS. Eu, Geziel Gomes Barbosa, digitei.